



权力挂起:行政组织法的新变式?

熊樟林*

内容提要 在我国行政组织法的发展与变革中,地方政府创生了一种在行政法理论体系上完全找不到对应的新型制度,它往往被称为“行政权力挂起”,是地方组织法的新变式。从对地方立法实践的观察来看,它是附随在权力清单制度中推进的,是为了应权力清单运动而催生的新型权力编排方式。但是,它既不是对行政权力的创设,也不是消灭,而只是采用一定的程序将行政权力予以冻结,被冻结的权力既可能会被长期封存,也可能被即时解封或启挂。从法律评价上来看,被挂起的行政权力可能会面临“是否具有合法性”、“是否构成违法性阻却事由”等多方面问题,尽管从理论层面上来说,这些问题可以在行政自制的制度定位中获得一定的解释。但是,这仍然不够,我们还需要从规范层面进行更为正式的制度化布置,并从法律效力上划定这一政治活动的最终边界,从而促使其从政治行为向法律行为转变,从封闭行为向开放行为转变。

关键词 行政权力挂起 行政不作为 行政组织法

问题提出

早在 20 世纪 80 年代,英国谢菲尔德大学(University of Sheffield)的普罗瑟(Tony Prosser)教授就曾说过:“行政法的理论只是相对的,有时并不能看到各个社会关系之间的联系”^①。因此,理论本身需要主动地去观察实践,“必须直面现代生活的理性化”,^②只有如此,我们方能获知“那些政策或教条是如何在实践中解决问题的”。^③在我国行政法实践中,此类事例非常多见,诸如“裁量基准”、“相对集中行政权”等问题,都需要我们奉行此类实用主义立场加以观察。^④

* 东南大学法学院副教授,法学博士。本文获 2015 年度国家社科基金青年项目“适合我国的行政裁量权基准制度构建研究”(项目批准号:15CFX021)资助,系江苏高校区域法治发展协同创新中心成果。

① Tony Prosser, *Toward a Critical Public Law*, *Journal of Law & Society*, Volume 9, Number 1, Summer, 1982, p. 1.

② [英]马丁·洛克林:《公法与政治理论》,郑戈译,商务印书馆 2003 年版,第 192 页。

③ Ronald M. Levin, *Administrative Law Pragmatism*, *Washington University Journal of Law & Policy*, 2011, 37, p. 230.

④ 关于行政法上实用主义立场的讨论, See also Sidney Shapiro, *Pragmatic Administrative Law*, from *The Reformation of American Administrative Law*, 2005, Article 1, pp. 1-23.



无独有偶,在近期我国行政组织法发展与变革中,一种为地方政府所推崇的、在行政法理论体系中找不到任何对应的新型制度,亦是其中一例,名为“行政权力挂起”。^⑤所谓行政权力挂起,“是指对行政执法机关具有法定依据的行政权力,在上一年度内未使用的,暂停其使用;如确需使用,须提前申报并事后备案的一种权力约束和动态管理机制”。^⑥在我国,它已在多个省份获得实施,^⑦并且多数地方已经建章立制。但对此,我国行政法学界却关注甚少。因而,本文特此就专门讨论,主要涉及以下问题:

第一,行政机关为什么要将其一直眷念的行政权力“挂起”而不用?

第二,哪些机关能够、又是按照何种流程将行政权力“挂起”的?被挂起的权力究竟处于什么状态?

第三,行政权力“挂起”真的会像现有舆论所说的一样有百利而无一害吗?

第四,如何解决行政权力挂起中存在的合法性问题?

一、行政权力挂起:权力清单制度的优化师

从对现阶段的观察来看,行政权力挂起是行政机关自发开展的。和“裁量基准”类似,^⑧它可算做是行政自制理念的一种表现形式。从根本上来说,它是道德自律,是行政机关自己给自己设定的义务。^⑨因此,对于某一项权力“挂”与“不挂”,全由行政机关自己定夺,行政组织法上并没有设定任何强制性义务。

那么,既然如此,行政机关为什么要将其一直“眷恋”的行政权力“挂起”而不用呢?他们真的已经如此“高尚”了吗?通过观察我们发现,这实际上和时下正在实施的权力清单制度存有密切关联。

权力清单制度,是十八届三中全会明确提出的一种权力监督方式。在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,党中央明确指出:“推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度,依法公开权力运行流程”。这一要求在四中全会里得到了延续,

⑤ 在地方实践中,与其类似的概念有“行政权力冻结”、“行政权力没收”、“行政权力暂停实施”等等。譬如,《山东省人民政府关于在全省推行行政权力清单制度的通知》(鲁政字〔2014〕141号)规定:“冻结虽有规章依据,但不符合全面深化改革要求和经济社会发展需要、一时难以通过修改相关规章调整或取消的行政权力,未经同级政府同意不得行使”;又如,《大庆市人民政府关于取消、下放和暂停实施行政审批以外行政权力事项的决定》(庆政发〔2015〕14号)、《吉林省清理和规范行政权力工作实施方案》(吉政发〔2011〕27号)等等。这其中,“行政权力冻结”、“行政权力没收”与“行政权力挂起”所要处理的权力对象基本相同,都是一些“合法有据但不合时宜的行政权力”。但是,“行政权力暂停实施”和“行政权力挂起”之间却存有差别。譬如,按照《吉林省清理和规范行政权力工作实施方案》(吉政发〔2011〕27号),行政权力暂停实施的前提条件是“法律依据不足和不符合我省经济社会发展实际的行政权力”。这与行政权力挂起存有差异。一般而言,被挂起的行政权力仍然是合法的权力,是享有法律依据的。因此,严格来说,被挂起的行政权力与被暂停实施的行政权力应属两种不同类型,不可同日而语。

⑥ 《晋中市行政权力挂起和解挂办法》,市政办发〔2014〕62号,载 <http://www.jiexiu.gov.cn/web/xxgk/zfxxgkml/zcfg/2014-12-01/20034.html>,最后访问时间:2017年9月7日。

⑦ 譬如山西省、安徽省、山东省、江苏省、黑龙江省等等。

⑧ 参见熊樟林:《裁量基准的控权逻辑》,载姜安主编:《行政法论丛》第13辑,法律出版社2010年版,第333页。

⑨ See also Robert A. Kagan, Inside Administrative Law, 84 Colum. L. Rev., 816-832 (1984).

在《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中,党中央将构建权力清单制度的具体任务细化为:“推行政府权力清单制度,坚决消除权力设租寻租空间”、“各级政府及其工作部门依据权力清单,向社会全面公开政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项”等等。

因此,按照中央的要求,所谓的权力清单制度,实际上是指政府及其职能部门将其所掌握的各项公共权力进行全面统计,“对每项职能进行细化后制成清单,并详细说明每项行政权的职能定位、管理权限、操作流程等”,“它主要是要用来指明行政权力所及的领域和范围,既表明了政府可以做的事情,也划定了行政权的边界”。^⑩从操作层面上来说,权力清单制度的核心任务,非但是要将政府所享有的权力制成清单,更为重要的是,它还要求将清单向全社会公布,以供民众监督。可见,蕴含在权力清单制度中的一个监督逻辑是:行政机关事先必须以权力清单的方式,将可以使用的权力公布于众,只有清单中的权力才是“合法正当”的,才能加以使用,而清单之外的权力则是“非法”的。

因此,为了“应付”、或者说为了规避清单制度可能带来的麻烦,减少其在行政效率上造成的消极影响,地方政府首先想到的办法,是尽可能地将所享有行政权力都列入权力清单之中,最大程度地将权力“上榜”。这其中,非但包括正在频繁使用的行政权力,也包括过去曾经大量使用但现阶段使用较少、以及一直都未使用但将来可能会启用的处于不同状态之下的各类行政权力。

实践中,倘若遵照此类安排,行政机关自当不会为权力清单制度所累,权力清单制度无非是“行政法律法规的细化和整合”,^⑪所谓的清单,也只是对行政机关已有权力的重申与复写,“那些看起来‘小而美’或‘整齐划一’的权力清单未必清晰可辨,有些只是换了个名头,有些做法甚至只是把碎片化的权力整合为更大的权力而已”。^⑫

但是,很显然,这和权力清单的制度初衷背道而驰,它只是摸清了行政权力的家底,对于“简政放权”的政治目标,^⑬功效甚微。并且,更为棘手的是,从解释学上来说,这一避法之术并没有违背权力清单制度的字面含义。事实上,权力清单只是要求行政机关将自己所享有的合法权力公布于众,并没有要求对各种状态下的行政权力进行分门别类。

因此,将不同状态下的所有行政权力都列入清单,只要它们仍然是合法的,便没有什么不当之处。也正因此,我们才会看到,来自政治学的研究者曾对权力清单制度毫不留情地抨击说:“权力清单的出台是在不触动基本权力结构的前提下做出的,也就是说,权力清单只是政府功能性权力的范围和职责的调整”、“并没有从基本政治框架和权力

⑩ 王春业:《论地方行政权力清单制度及其法制化》,载《政法论丛》2014年第6期。

⑪ 前引⑩,王春业文。

⑫ 周庆智:《控制权力:一个功利主义视角——县政“权力清单”辨析》,载《哈尔滨工业大学学报》(社会科学版)2014年第3期。

⑬ 参见喻少如:《权力清单制度中的公众参与研究——兼论权力清单之制度定位》,载《南京社会科学》2016年第1期。

结构上着手,并对行政权力做出实质性的调整和调适”。^⑭

可见,按照这个逻辑,“简政放权”单单依靠权力清单制度是无法实现的。在行政权力的组织上,它需要一个更为明确的优化方案,而这便是行政权力“挂起”制度。行政权力挂起是建立在权力清单制度之上的,它既可以被算作是权力清单的附属品,同时也可以说是权力清单制度的优化师。

从对地方实践的观察来看,将行政权力挂起,就是为了规避行政机关在执行权力清单制度上可能会采行的上述规避之策。实践中,一旦行政权力挂起制度得以配套,权力清单制度的含义便演变为:行政机关在权力清单中只需公布经常使用的各项行政权力,而对于经常不使用的权力,则可以不列入清单之中,而将其挂起,使其处于冻结状态。当然,如若需要,亦可申请解挂。这一方面既可以达到权力清单制度意欲实现的简政放权之效果,同时另一方面,也可以打消行政机关的丧权之忧。

因此,在权力清单制度推行过程中,行政权力挂起籍由两方的大力推行,几乎占据了此次行政组织法改革的半壁江山。譬如,以山西省晋中市为例,其在2014年8月的行政权力清理过程中,涉企权力项目5175项,其中,清单公布1874项,挂起3301项。^⑮又如,以江苏省扬州市为例,该市2014年共有涉企行政权力4776项,但其中挂起便有3029项之多,等等。^⑯

二、行政权力挂起的运行逻辑

作为我国行政组织法的一项新型事务,行政权力挂起既没有理论研究上的任何成果可供参考,也没有比较法上的任何模型可供效仿,它从一开始就是摸着石头过河的,运行逻辑十分朴素,从如下三个方面便可大致获知:

(一)行政权力挂起的选择标准

作为权力清单制度的瘦身利器,行政权力挂起首先需要解决的问题是哪些行政权力应该被挂起,这一选择范围的大小,直接决定了权力清单制度的基本牌面。

从对地方立法实践的观察来看,立法者似乎并没有一个十分明确的操作标准,各地做法不一,各有千秋。譬如,对于可供选择的权力类型,《无锡市行政权力“挂起”试行办法》规定的选择标准是十分模糊的“极少使用”。^⑰但是,类似的情况,《晋中市行政权力挂起和解挂办法》却规定得十分明确,限制为“在上一年度内未使用的”行政权力。很显然,这必然会在一定程度上影响到我们对行政权力挂起选择范围的判断。不过,尽

^⑭ 前引⑫,周庆智文。

^⑮ 苗武军:《晋中“挂起”2/3涉企权力》,载《山西日报》2014年8月7日第A01版。

^⑯ 扬州市人民政府法制办公室:《扬州市政府法制办完成涉企权力清理审核确认工作》,载 http://www.jsfzb.gov.cn/art/2014/3/19/art_106_39576.html,最后访问时间:2017年9月8日。

^⑰ 参见《无锡市行政权力“挂起”试行办法》,崇政办发〔2010〕22号,载 <http://www.lawxp.com/statute/s1541414.html>,最后访问时间:2017年9月7日。

管如此,我们还是从中找到了一些具有共性的标准可供参考,这主要包括:

1. 合法的权力。被选择挂起的行政权力,首先必须是合法的权力,这是行政权力挂起的制度前提。实践中,行政权力挂起虽然能够起到权力暂停状态的法律效果,但并不意味着权力丧失,在多数情况下,它仍然会被重新启用。因此,被挂起的行政权力与被取消的行政权力截然不同,它从根本上来说仍然是一项合法权力,这正是将行政权力挂起作为权力清单配套制度的根本所在,也是各地立法文本中必须言明的首要条件。譬如,《晋中市行政权力挂起和解挂办法》第2条规定:“本办法所称行政权力挂起是指对行政执法机关具有法定依据的行政权力,在上一年度内未使用的,暂停其使用;如确需使用,须提前申报并事后备案的一种权利约束和动态管理机制”。^⑩这其中,“行政执法机关具有法定依据的行政权力”,正是在为被挂起的行政权力设定“合法性”的限制条件。

2. 闲置的权力。不唯上述,被选择挂起的行政权力还必须是闲置的权力。从对地方立法文本的观察来看,被挂起者具有一个固定属性,这便是它们在特定的时段内往往是不具有现实意义的,可操作性较弱,无法被应用到行政机关当下的行政活动之中。用更为通俗的话说,它们就是一种被闲置的权力,这是挂起一项行政权力最为核心的判断标准。在地方立法中,多数文本对此都着墨较多,通行方式是在定义中以“长期不使用”、“极少使用”、“在上一年度内未使用”等等之类的表述加以框定。譬如,《宿迁市政府法制网上监督系统管理暂行办法》第9条规定:“有下列情形之一的,部门可以申请挂起行政权力事项:(一)行政权力事项一年以上未发生办件的;(二)周期性办理的行政权力事项,在本次办理周期结束至下次办理周期开始期间……”等等。^⑪

3. 可用的权力。被选择挂起的行政权力,最后还必须是一项可用的权力。需要指出的是,上述有关“闲置的权力”的判断,必须要放在阶段性的时空当中加以评价。有关是否闲置的定性,也只是在某一个固定的时间之内才是适宜的。否则,倘若将判断的时空拉长,被挂起的行政权力便仍然会呈现出“可用”的实践价值,在以后的公务活动中,它可能会继续扮演重要角色。因此,被挂起的行政权力实际上仍然是具有使用价值的,只不过,现阶段还不具备释放这一使用价值的客观条件,这正是区分被挂起的行政权力和被取消的行政权力的关键所在。

从对地方立法实践的观察来看,被挂起的行政权力的预期使用价值,往往会藉由如下两种通道获得实现:(1)几乎所有文本都会设计相应的解挂条件和方法,从而为被挂起的行政权力设定豁免机会。如江苏省《淮安市行政权力“挂起”试行办法》第8条规定:“对已经‘挂起’的行政权力,行政主体因实际情况需要‘解挂’的,应当向同级政府法制部门申报,并说明原因”等等;^⑫(2)部分文本还特别规定,被挂起的行政权力尽管

⑩ 前引⑥。

⑪ 《宿迁市政府法制网上监督系统管理暂行办法》,宿政办发[2010]160号,载 http://www.fae.cn/fg_detail15393023.html,最后访问时间:2017年9月8日。

⑫ 《淮安市行政权力“挂起”试行办法》,载 <http://admin.huaian.gov.cn/web/center/zxbd/zxzt/dz/2010/07/26/864501.html>,最后访问时间:2017年9月8日。

不能加以使用,但依然需要向社会公布,相对人在承载政府信息的公共平台上依然可以查询到这一行政权力。譬如,南京市鼓楼区《行政权力事项挂起与保留的相关说明》指出:“行政权力事项挂起后,在市级前台(南京市政务大厅)依旧可以看到,在市级后台(市监察监控系统)呈挂起状态显示”等等。^②这意味着,对于行政相对人来说,被挂起的行政权力的使用价值并没有受到影响,立法者对其使用价值的冻结,只是会单向性地施加到行政主体之上,而不会波及相对人。

(二)行政权力挂起的决定权限

由于在权力清单的制度范围之内,被挂起与被列入清单之内的行政权力的“政治合法性”截然不同,中央文件规定,只有清单上的权力才能够加以使用,而被挂起的行政权力则需要暂时封存。因此,挂起一项权力,最终必然会引起行政组织法上法律效果的变更,尽管这可能并不被逻辑严谨的公法学界所认可,但是从功能主义的立场来说,这是一项不可忽视的后果。因此,由谁来最终敲定是否挂起一项行政权力,意义重大。对此,地方立法主要有以下四种布置思路:

1. 不加以限制。在部分权力清单实施意见中,我们虽然也能读到类似与权力挂起的权力冻结制度,但是,决策者显然并没有虑及决策权问题,相应文本对此也只字未提,我们也没有查阅到具体的操作办法。譬如,《芜湖市人民政府关于推行市级行政权力清单制度的实施意见》规定:“有法律法规规章依据、但不符合全面深化改革要求和经济社会发展需要、一时难以通过修改相关法律法规规章调整或取消的行政权力,以及日常管理中很少行使、责任不明的行政权力,应当予以冻结”;^③又如,宣城市《郎溪县人民政府关于建立政府权力清单和责任清单制度的实施意见》规定:“有法律法规规章依据、但不符合全面深化改革要求和经济社会发展需要、一时难以通过修改相关法律法规规章调整或取消的行政权力,以及日常管理中很少行使、责任不明的行政权力,可不列入权力清单,实行动态管理”等等。^④

2. 政府或政府部门首脑。基于我国各级人民政府实行的是行政首长负责制,行政首长对本行政组织所管辖的重要事务具有最后决策权,并对此全面负责。因此,从政治常识上来说,行政权力挂起亦应遵循首长负责制基本原理,必须将大权交由政府首脑行使。实践中,类似的文本十分常见。譬如,江苏省新闻出版广电局(版权局)《行政权力

^② 南京市鼓楼区《行政权力事项挂起与保留的相关说明》,载 http://fzb.njgl.gov.cn/art/2011/5/31/art_15246_994242.html,最后访问时间:2015年3月10日。需要说明的是,被挂起的行政权力是否仍然需要向行政相对人公开,各地做法并不相同。譬如,《南通市通州区环境保护局行政权力网上公开透明运行管理办法》(通环[2010]114号)第13条规定:“行政权力事项的挂起与解挂,采取部门申报,区监察局、区政府法制办联合审核的方式。部分按照规定不宜公开、网上公开透明运行条件尚不成熟、法律法规赋予但一年以上未行使的行政权力可申请行政权力挂起,同意后暂不在网上公开透明运行”等等。

^③ 《芜湖市人民政府关于推行市级行政权力清单制度的实施意见》,载 http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=17654671,最后访问时间:2017年9月8日。

^④ 《郎溪县人民政府关于建立政府权力清单和责任清单制度的实施意见》,郎政[2014]31号,载 <http://www.ahlx.gov.cn/web/Content.aspx?chn=23&id=40693>,最后访问时间:2017年9月12日。

挂起操作办法》第4条规定:“符合挂起条件的行政权力需要挂起的,由行使该权力的业务处室提出书面申请,经局办公室(政策法规处)、监察室审核后,报局领导同意后挂起”等等。^②

3. 政府法制部门。有所不同的是,在一些对法制工作较为重视的地区,立法者往往会将权力挂起的决定权限交由政府法制部门审核确定,具体是指设立于人民政府内部的法制办公室(简称法制办),或者是设立于政府部门内部的法规处(简称法规处)。在各地文本中,这两类内设机构都在一定程度上享有权力挂起的决策权限,二者的分工可以被简单地理解为“初审”和“终审”两项工作,法制办享有最终决策权。而且,立法者通常也会将决策权一律上收,统一打包给同一级人民政府法制办最终处理。譬如,《江苏省行政权力网上公开透明运行管理暂行办法》第18条规定:“对长期不使用的行政权力,实施主体应向同级人民政府法制机构申请暂停行使,具体办法另行规定”;^③《苏州市行政权力库更新维护办法》第9条规定:“政府法制机构负责行政权力库中行政权力的‘挂起’和‘解挂’工作,各部门、各直属机构具体负责本部门行政权力‘挂起’和‘解挂’的初审工作”等等。^④

4. 行政权力的设定机关。还有一些更为灵活且颇具“解铃还须系铃人”逻辑色彩的方法,是将大权交由被挂起的行政权力的设定机关亲自“操刀”的。相对而言,这类方法更为原则,也似乎更加尊重行政组织法的基本原理,但基于它可能会跳脱各地法制办经常采用合法性审查程序的监督,因此现行文本并不多见,我们能够查阅到的主要是《黑龙江省人民政府关于推行政府权力清单制度的指导意见》。该意见规定:“有法定依据,但不符合全面深化改革要求和我省实际,没有管理对象,多年不发生管理行为,一时又难以通过修改相关法律法规规章调整或取消的行政权力,经该行政权力设定机关同意后可以暂时停止实施。需要恢复实施的,须经设定机关同意后方可行使”。^⑤

(三)行政权力挂起的效力状态

现阶段,地方文本一般并不会直接对被挂起的行政权力的效力状态加以规定,我们往往需要从行政权力挂起的定义中方能获取。譬如,《淮安市行政权力“挂起”试办法》第4条规定:“本办法所称‘挂起’,是指行政主体依法享有行政权力,但由于长期不使用或者使用频率较低,该行政权力不再在行政权力网上运行公示数据库中反映,在实际工作中也不再行使”。在这一条文中,权力挂起的效力状态表现为两个方面:(1)从权力公开层面将此类权力剔除于权力清单之外,即第4条中规定的“不再在行政权力网上

^② 江苏省新闻出版广电局(版权局)《行政权力挂起操作办法》,载 <http://www.jsjd.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=8964>,最后访问时间:2015年3月18日。

^③ 《江苏省行政权力网上公开透明运行管理暂行办法》,苏政办发[2010]140号,2010年11月30日公布。

^④ 《苏州市行政权力库更新维护办法》,苏府法[2010]20号,2010年6月9日公布。

^⑤ 《黑龙江省人民政府关于推行政府权力清单制度的指导意见》,黑政发[2015]9号,2015年3月7日公布。

运行公示数据库中反映”;^②(2)从操作层面上限制此类行政权力的使用,即第4条中规定的“在实际工作中不再行使”。按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的要求,这两者是依次递进的,前者是因,后者为果,不被权力清单收录的权力事项,在实际工作中就不能加以使用。因此,从这一点上来说,上述规定是十分适宜的。简而言之,它给行政权力挂起所安排的效力状态,就是“暂时不再使用”。

但是,这依然没有触及到问题的核心。实际上,行政权力挂起的效力状态还需要从如下四个方面加以补足:

1. 首先需要注意的是,尽管被挂起的行政权力“在实际工作中不再行使”,但这并不意味着此类行政权力是非法的,恰恰相反,它实际上仍然是合法的。如上所述,挂起一项行政权力的首选标准就是被选对象为合法权力,它在被挂起之前是合法的,在被挂起之后,并不会发生改变。“权力挂起”这一动作并不能作为一项正当性阻却事由,用以强制性中断被挂起的行政权力的合法效果,这是决定之所以挂起一项权力而不是取消一项权力的关键所在。因此,从整体上来说,被挂起的行政权力仍然是一项合法权力,它在行政组织法上依然是名正言顺的。

2. 但是,应当加以限定的是,我们所说的被挂起的行政权力是合法的,只是从法律评价上而言的,并不代表它在其他的评价通道中仍然是合法的。按照各地规定,被挂起的行政权力往往需要置于权力暂停状态。因此,它的合法性实际上是大打折扣的,这很明显与一项合法行政权力应当具有的效力状态有所出入。因此,需要加以区分的是,地方文本中所提出的诸如“权力暂停状态”之类的对行政权力合法性效力内容的压缩,只是差别性地从政治评价上强加的,它的依据是诸如《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》之类的中央文件,它本身并不能阻止法律评价上的合法性结论,至少从行政法组织法上来说,这一点是确信无疑的。

3. 因为“权力暂停状态”只是政治评价,它从根本上来说的是行政机关内部的自我监督措施,是行政自制,是行政机关自我设定的义务。因而,挂起制度对行政权力效力内容的压缩或冻结,只能单向性对行政机关自身生效,并不能扩及到行政相对人。对于行政相对人而言,权力清单中被挂起的行政权力与未被挂起的行政权力的效力角色,并没有实质性差别,只是在某些地方,我们会从视觉效果上感到部分差异,这是因为,被挂起的行政权力往往不会在各地行政权力运行数据库中加以显示,但这只是物理层面上的后果,与合法性效力本身毫无关联。

4. 类似地,因为“权力暂停状态”只是政治评价,被挂起的行政权力仍然是合法的,

^② 需要注意的是,并不是所有的地方政府都不将挂起的行政权力置于行政权力网上运行数据库中加以公开,这其中亦有例外,如上文提到的南京市鼓楼区《行政权力事项挂起与保留的相关说明》便明确指出:“行政权力事项挂起后,在市级前台(南京市政务大厅)依旧可以看到,在市级后台(市监察监控系统)呈挂起状态显示”。

因此几乎在所有的权力挂起制度中都会设定相应的解挂程序,这一方面可以算作是对被挂起的行政权力的合法性效果的承认,同时,其实际上也是在为串联政治评价和法律评价构建通道,解挂的基本作用就是消除政治评价的后果,恢复被挂起的行政权力应有的合法性内容。实践中,这样的文本十分常见。譬如,《滨海县行政权力挂起和解挂办法》第2条规定:“本办法所称行政权力解挂是指对已挂起的行政权力,由于客观原因确需行使的,解除原挂起状态而恢复行政权力正常动态运行并纳入行政权力动态运行的数据统计的一种行政权力处理方式”等等。^②

三、行政权力挂起的制度风险

毋庸置疑,权力挂起是具有一定的实践意义的,这主要表现在两个方面:其一,从政治评价上压缩了原有的权力结构,使得在官僚系统内部,真正具有使用价值的行政权力的实际数量锐减。而且,从统计数据上来看,被挂起的行政权力的数量几乎都高达一半以上。很显然,这在一定程度上已经形成了一种大规模的、政治性的组织法效果,能够为传统行政法控权模型提供新的发展指向,甚至说能够倒逼行政组织法的自我革命;其二,从功能评价上大大提高了行政权力的运行率,有利于充分发挥行政机关的积极主动性,尤其是对“行政奖励”、“行政确认”等运用率较低的传统行政权力而言,这更是一项可贵的督促措施。而且,提高给付性行政行为的使用效率,也能够从整体上改善行政执法环境,进一步贴近服务行政的时代背景。

正因如此,从我们能够观察到的情况来看,现有舆论对挂起制度的评价是十分积极的,认为其“彰显了建设服务型效能政府的高度自觉”,^③是“创新行政模式的出发点”。^④但是,权力挂起是否真的有百利而无一害呢?本文认为,答案可能并不那么简单,实际上运用行政组织法基本原理,我们依然可以找到暗存在其中的制度风险,具体如下:

(一)行政权力挂起与权力清单制度

行政权力挂起是作为权力清单的配套制度而创设的。权力清单制度要求,只有在清单上公布的行政权力才能够加以使用。因此,行政机关基于“丧权”之忧,往往会将所有行政权力都公布于清单之上,但这与“简政放权”的政治目标相去甚远。因此,为了避免此类只能在“是”与“非”之间做单项选择的缺陷,地方政府便创设了权力挂起制度,添加了一个中间的权力暂停状态,从而起到了一定的缓冲作用。

这本身是无可厚非的,也确实能够平衡政治理想与社会现实之间的紧张关系。但是,问题在于按照这一逻辑,权力挂起可能是一把双刃剑,其在满足实践需求的同时,也

^② 《滨海县行政权力挂起和解挂办法》,载 <http://xxgk.binhai.gov.cn/qt/news1.asp?InforOpenDirID=1981>,最后访问时间:2017年9月8日。

^③ 白昌华:《在改革中释放发展活力——经济下行压力下市委市政府抢抓机遇转型发展》,载《晋中日报》2014年9月3日,第001版。

^④ 顾日红、胡广伟:《“权力阳光”驱动政府自我革命:江苏的实践》,载《电子政务》2014年第2期。

会伤害到权力清单的政治实效。这是因为,实践中可能会出现某些地方政府凭借权力挂起的制度通道,将一些不具有合法性的、应当加以清理的行政权力,同样也予以挂起,从而避开“权力清单制度”这一阶段性的监督工具。对此,我们可以从一些简单的挂起数据上加以观察。譬如,在前述山西省行政权力清理过程中,权力事项共计 5175 项,其中被挂起的行政权力高达 3301 项,占比约为 64%。^② 在扬州市 2014 年权力清理过程中,情况类似,被挂起权力 3029 项,占比约为 63%,等等。^③

从这些数据中我们不难发现,被挂起的行政权力是占据多数的,几乎囊括了绝大多数的行政权力,并没有给取消或清理其他行政权力留下任何空间,而这最终必然会架空整个权力清单制度。这是因为,按照中共中央办公厅、国务院办公厅颁布实施《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》的要求,推行权力清单制度的基本目标是给行政权力减肥,清理或取消部分行政权力。该文件指出:“大力清理调整行政职权。在全面梳理基础上,要按照职权法定原则,对现有行政职权进行清理、调整。对没有法定依据的行政职权,应及时取消……;对虽有法定依据但不符合全面深化改革要求和经济社会发展需要的,法定依据相互冲突矛盾的,调整对象消失、多年不发生管理行为的行政职权,应及时提出取消或调整的建议”。^④

但是,实践中,大量被收编至“可被挂起”范围内的行政权力,在效力上只是“权力暂停状态”,而非权力的清理或取消。而且,按照地方立法文本的规定,被挂起的行政权力在条件成熟的情况下,仍然可以复活,这一程序往往被称之为“解挂”。譬如,《苏州市行政权力库更新维护办法》第 12 条规定:“需要对‘挂起’的权力事项予以‘解挂’的,由行政权力所属部门通过行政权力网上运行系统上报市政府法制机构审核,并同时提交加盖单位公章和单位负责人签字的纸质行政权力‘解挂’申请报告”等等。^⑤ 很显然,这与权力清单的制度初衷是相违背的,其只是地方政府应付权力清单制度的便宜之举,并不会产生组织法上的直接效果,权力清单制度价值也会因此而大打折扣。

(二)行政权力挂起与职权法定原则

所谓职权法定原则,是指行政机关的职权和管辖必须有明确的法律依据,其来源于“人民是权力的惟一合法泉源”和“原始权威”的简单逻辑。^⑥ 在行政法上,“行政职权必

^② 前引^①,苗武军文。

^③ 前引^①。

^④ 实际上,在权力清单制度推行过程中,地方政府的目标更加明确,就是要“取消没有法定依据的行政权力事项”。依次参见《安徽省人民政府关于推行省级行政权力清单制度的通知》,皖政〔2014〕29号;《福建省推行省级行政权力清单制度实施方案》,闽政〔2014〕20号。

^⑤ 类似立法亦有如:《滨海县行政权力挂起和解挂办法》第2条第2款:“本办法所称行政权力解挂是指对已挂起的行政权力,由于客观原因确需行使的,解除原挂起状态而恢复行政权力正常动态运行并纳入行政权力动态运行的数据统计的一种行政权力处理方式”;《泰州市市级行政权力事项目录清单管理办法》第11条第2款:“行政主体不得因行政权力事项挂起而怠于履行职责。当挂起事项发生办件时,应当即时申请恢复行使权力,不得因事项处于挂起状态而网下运行”。

^⑥ [美]汉密尔顿、杰伊、麦迪逊:《联邦党人文集》,程逢如等译,商务印书馆1980年版,第257页。

须合法产生,行政主体行政职权或由法律、法规设定,或由有权机关依法授予,否则权力来源就没有法律依据,而没有法律依据的行政权从根本上来说是一种非法的权力”。^{③⑦}这是对权力来源的要求,是对职权法定原则最为朴素的理解。一般来说,职权法定原则包含两个层面的操作要求:其一,行政职权来源法定,主要是指行政权力必须通过立法方式加以设定,“只有通过立法设定和赋予的职权才是合法的职权,立法以外的其他途径不能产生行政职权”;^{③⑧}其二,行政职权范围法定,主要是指行政职权的适用对象和范围也必须由立法加以确定,否则就会超越职权。

现阶段,职权法定原则已经成长为行政组织法上的基本原则,“在西方国家已成为行政法治的应有之义”。^{③⑨}譬如,在德国,“管辖权规则通常由法律规定和调整”。^{④①}在日本,“行政官厅的权限范围,当有关权限的行使存在法律的根据时,限于该根据法律所规定事项的范围。即使在不需作用法上的根据的情况下,也必须是组织规范所规定的所掌事务的范围内。其所掌事务的范围,在国家层面,以各省设置法规定;在地方公共团体层面,根据《地方自治法》及条例规定”。^{④②}在我国台湾地区,“基于法治国家法律安定之要求,管辖权之规定,无论涉及行政机关对人民为干涉或给付之权限,皆应以外部法之法规规定之”等等。^{④③}

相应地,在我国,职权法定原则也有基本的制度布置:首先,在宪法层面,《宪法》第89条、第107条分别对国务院和地方政府的权力来源作了列举和概括式的规定,其中第107条更是采用了“法律规定的权限”之类的表述,这是对职权法定原则的最高立法规划;^{④④}其次,在部门法层面,职权法定原则也一直被作为管控行政权的主要抓手,其典型立法例是《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政强制法》有关行政处罚、行政许可以及行政强制设定权划分的规定;^{④⑤}最后,在地方行政程序规定中,立法者还特别对职权法定原则予以列明。譬如,《湖南省行政程序规定》第11条规定:“行政机关的职权和管辖权依照法律、法规、规章规定”;《山东省行政程序规定》第12条规定:“行政机关行使行政职权应当依照法律、法规、规章的规定”;《江苏省行政程序规定》第9条规定:“行政机关行使行政职权应当依照法律、法规、规章规定”等等。

可见,无论是在国外,还是国内,职权法定原则都不是一个纯粹的学术概念,它作为公法领域中的一项基本准则,已经深入到依法行政的各个角落。根据职权法定原则的

③⑦ 周佑勇:《行政法基本原则研究》,武汉大学出版社2005年版,第167页。

③⑧ 杨小君:《契约对行政职权法定原则的影响及其正当规则》,载《中国法学》2007年第5期。

③⑨ 应松年、薛刚凌:《行政组织法研究》,法律出版社2002年版,第57页。

④① [德]汉斯·J·沃尔夫、奥托·巴霍夫、罗尔夫·施托贝尔:《行政法》(第3卷),高家伟译,商务印书馆2002年版,第161页。

④② [日]盐野宏:《行政组织法》,杨建顺译,北京大学出版社2008年版,第23页。

④③ 陈敏:《行政法总论》,自版2009年版,第934页。

④④ 《宪法》第107条:“县级以上地方各级人民政府依照法律规定的权限,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作,发布决定和命令,任免、培训、考核和奖惩行政工作人员”。

④⑤ 依次参见《行政处罚法》第9-14条、《行政许可法》第14-17条、《行政强制法》第10-11、13条。

要求,各个行政机关的具体任务、主管事项、权限以及内部机构的设置和编制,都应该以法律、法规以及规章为准,而不是某一个行政机构或规范性文件。换句话说,决定一个行政机关享有多少权力内容,不是由政府内部决定的,它往往需要由立法机关才能敲定,而这当然也包括取消和暂停一项合法行政权力的法律效果在内。

但是,问题在于行政权力挂起并不符合上述原理。诚然,从功能主义层面而言,被挂起的行政权力在政治层面上的评价,与在法律层面上的评价迥异。并且,中共中央办公厅、国务院办公厅在其颁布实施《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》也只是规定:“对虽有法定依据但不符合全面深化改革要求和经济社会发展需要的,法定依据相互冲突矛盾的,调整对象消失、多年不发生管理行为的行政职权,应及时提出取消或调整的建议”,并没有说行政机关可以直接取消或调整某一项行政权力。

不可否认,一旦一项行政权力被挂起,它在一个特定的时间范围内就是毫无意义的,不能被用于行政管理活动。因此,“挂起”实际上就是一种行政职权的变更,尽管此类变更往往只是暂时的,并没有从根本上改变权力的属性,但这并不妨碍它在组织法上的基本定位。因此,严格来说,行政权力挂起仍然需要服膺于职权法定原则的规范,经由立法方式实现,而不是像现在这样通过政策、文件的形式,以下达任务指标,从政治层面对已经合法的行政权力“任意设定或变更”。^⑤ 笔者认为,这是对职权法定原则的违背,不具有宪法层面的正当性,“职权法定”中的“法”应当是指“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章”三类五种的集合体,^⑥而不是一纸文件。

(三)行政权力挂起与行政不作为

由于一项合法的行政权力一旦被挂起,就会面临“暂时不再使用”的效力状态,而且,“权力清单是各级政府依法行政的依据,不在权力清单范围内的,不得实施”。^⑦ 那么,实践中可能会产生的问题是,行政机关如果真的遵循权力挂起而拒绝对某一类事项提供公共服务时,会不会构成行政不作为?或者说,如果因为权力挂起而导致行政相对人人身和财产权受到损害,相对人是否可以提起行政不作为诉讼?^⑧ 对此,我们需要从如下两个方面入手:其一,行政不作为中的义务来源,究竟包括不包括被挂起的“法定职权”?其二,“权力挂起”这一行为是否能够成为豁免行政不作为法律责任的正当理由?

1. 第一个问题的答案应该是十分明确的,在我国理论研究中,有关行政不作为构成要件的讨论都对此不置可否。一般认为,主要包括三个方面:作为义务的存在、作为之可能性、以及客观上没有作为。三者之中,作为义务是前提,“行政不作为的构成必须以

^⑤ 前引④,陈敏书。

^⑥ 方润、邢昕:《论权力清单与职权法定的内在逻辑》,载《广西政法管理干部学院学报》2016年第5期。

^⑦ 王春业:《论权力清单制度对行政权的控制与规范》,载《福建行政学院学报》2014年第6期。

^⑧ 类似案例,依次参见“李伟光诉浙江省水利厅不履行法定职责案”,(2014)浙杭行终字第360号;“耒阳市金山现代城小区诉耒阳市物价局不履行法定职责案”,(2013)耒行初字第106号。等等。

作为义务为前提,无作为义务的存在则无行政不作为”。^④ 现阶段,尽管理论界对作为义务的来源存有争议。但是,这并不妨碍我们对权力挂起问题的判断,因为在不作为的所有义务来源中,其中的“法律直接规定的行政作为义务”,^⑤已经获得多数人的认同,其常常被称之为“法定义务”,主要是指“来源于法律、法规、规章等法律规范对行政主体职权和职责的规定”。^⑥ 这等同于说,由法律、法规、规章直接授予的行政权力,行政机关如果能够行使但却未行使,有可能就是一种典型的行政不作为。

如前所述,在行政权力挂起中,被挂起的行政权力几乎都是“法律直接规定的”职权。譬如,《晋中市行政权力挂起和解挂办法》第2条规定:“本办法所称行政权力挂起是指对行政执法机关具有法定依据的行政权力”等等。^⑦ 这些被挂起的权力首先是具有法定依据的,是“法律直接规定的”的职权,符合上述条件。

在传统行政法学中,职权与法定义务并不当然等同,甚至于有人认为,“职权”并非“职责”,“组织规范”中更多的是“职权规范”,而不是“职责规范”,前者是“赋权”,而后者是“促责”,^⑧二者不可混谈。否则,“则是荒谬的”。^⑨ 因此,被挂起的行政权力作为一种职权,是否真的能成为上述“法定义务”,便不得不一议。对此,笔者认为答案应该是肯定的,需要区分的是,“法律授予行政机关职权,实际上也赋予了行政机关义务和责任”。^⑩ 实践中,“行政机关不履行义务可以采取多种形式,包括不行使权力在内”。^⑪ 因此,“行政主体不履行法定义务,不仅应包括不履行法定职责,还应包括不行使职权在内”。^⑫ 在以行政主体法定义务为标准评价行政行为的方式时,不能仅仅注重该义务来源于法律规范对行政主体职责的规定,而忽略它也可来源于法律规范对其职权的规定。从法律上来说,“法律赋予行政机关行使一定的职权,同时就意味着规定了国家行政机关的法定职责,即职权就是职责”。^⑬ 因此,被挂起的行政权力,对行政机关来说既是一种权力,也是一种义务。当其作为一项义务时,“当然不能自行处分”,^⑭否则就是一种不作为。

2. 权力挂起是否能够作为排除行政不作为的一项豁免理由? 现阶段还无法获得定论。从总体上来看,权力挂起依托的政治背景是权力清单制度,人们如何看待权力清单,会直接决定权力挂起的性质定位。但问题在于,现阶段,权力清单本身的制度定位

④ 参见周佑勇:《行政不作为构成要件的展开》,载《中国法学》2001年第5期。

⑤ 当然,此处的“法律”是广义的,包括法律、法规、规章、以及其他规范性文件。

⑥ 前引④,周佑勇文。

⑦ 前引⑥。

⑧ 参见柳砚涛:《论积极行政法的构建——兼及以法律促进行政》,载《山东大学学报》(哲学社会科学版)2013年第3期。

⑨ 方世荣:《再论具体行政行为的几个基本理论问题》,载《法商研究》1994年第6期。

⑩ 李步云、刘士平:《论行政权力与公民权利关系》,载《中国法学》2004年第1期。

⑪ 王名扬:《英国行政法》,北京大学出版社2007年版,第131-132页。

⑫ 前引④,周佑勇文。

⑬ 刘旺洪:《论法治政府的标准》,载《政法论坛》2005年第6期。

⑭ 前引⑤,李步云、刘士平文。

也是存有争议的。在政治活动中,中央高层的制度部署是将其作为行为依据。譬如,中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》中(中办发[2015]21号)提出的要求是:“严格按照权力清单行使职权,切实维护权力清单的严肃性、规范性和权威性……对不按权力清单履行职权的单位和人员,依纪依法追究责任”;又如,国务院在《国务院办公厅关于公开国务院各部门行政审批事项等相关工作的通知》中(国办发[2014]5号)采用的表述是:“各部门不得在公布的清单外实施其他行政审批”等等。按照这一部署,权力清单“不仅是行政管理的依据,也是规范行政人员按照清单行使权力的依据”,^⑥“不属于清单列举范围内的职能和权限,行政机关不得为之”等等。^⑦据此,由于被挂起的行政权力不在清单之列,行政机关不享有原本“法律直接规定的职权”,其以清单而不作为,自当可以免责。

但是这一切只是权力清单制度在政治层面的愿景。在公法学界,有人对此提出了十分强烈的批评,他们曾不留情面地说:“权力清单既不是法,也不是规范性文件”,^⑧权力清单非但不是行为依据,同时也不在依法行政中“实质法”的行列。^⑨在他们看来,权力清单制度、以及围绕在权力清单制度周围的其他一系列活动,包括行政权力挂起制度在内,都只是一场经由政策途径而推行的政治运动,与法的关联十分有限,与行政组织法更是难以周延。“在改革实践中,不能把具有丰富内涵的现代依法行政,形而上学、简单僵化地解读和操作为‘依清单行政’”。^⑩同时,我们也不能说,“清单之外无权力”,我们只能说要依法行政,但不能说“依清单行政”。^⑪因此,被挂起的行政权力,依然还是“法律直接规定的职权”,是行政不作为的作为义务来源。如果行政机关以某项权力被挂起而拒绝行使,其当然是有可能需要承担行政不作为的法律责任的。此正如学者所言:“对因权力清单而产生的‘越权’或‘不作为’,行政相对人有权提起行政复议或行政诉讼,但其依据应当是‘法’,而‘权力清单’则是支持其诉求的证据”。^⑫

四、行政权力挂起的制度定位与合法化设计

可见,行政权力挂起工作仍然需要从规范层面进行更为正式的制度化布置。对此,笔者认为,应当明确其行政自制属性的制度定位,并以此为基础,从法律效力上划定这一政治活动的权力边界,从整体上做全方位的合法化设计。

(一) 行政自制:行政权力挂起的制度定位

⑥ 吴常幸:《“权力清单”制度的政治学意义》,载《党政论坛》2015年第5期。

⑦ 任进:《权力清单和负面清单的法治意义》,载《学习时报》2014年1月27日第5版。

⑧ 申海平:《权力清单的定位不能僭越法律》,载《学术界》2015年第1期。

⑨ 依法行政中的“法”,并不仅限于立法机关制定的法,而是表现为多个主体共同参与、多层规范依次细化的复杂过程。参见前引⑤,周佑勇书,第172-173页。

⑩ 莫于川:《推行权力清单,不等于“依清单行政”》,载《中国司法》2014年第6期。

⑪ 杨登峰:《正确认识政府权力清单与法的关系》,载《中国党政论坛》2016年第4期。

⑫ 前引④,方润、邢昕文。

准确的制度定位,是决定行政权力挂起活动法律效力的关键,是原理性答案。实践中,无论是其与职权法定原则之间的关系,还是与行政不作为之间的关系,最终都需要从制度定位上予以解答。行政权力挂起应当定位成一种行政自制行为,或者说是一种自制型的行政行为。所谓“行政权力挂起”,是指行政机关根据党和国家的政策指示,对法定授权的行政职权予以冻结并暂停使用的一种单向性的权力处分行为,其目的在于对行政权的积极行使形成一种政治性的自我约束。作为行政自制行为的权力挂起活动,奉行的是一种可被称为“行政自制”的控权逻辑,^⑥是行政机关自己在为自己设定义务,是一种作茧自缚的道德自律。^⑦在某种程度上,我们可以说,整个行政权力挂起的制度功效都需要从这一点上获取,而且实践中也需要以此为逻辑起点,划定行政权力挂起行为的权力边界。具体来说,这主要包括如下两个方面:

1. 行政权力挂起只是一项政治活动。首先需要明确,行政权力挂起并不是一项正式的法律活动,不是按照立法程序所做的规定动作,而只是行政机关根据自己的工作习惯和工作需求自发决定的。从本质上来说,行政权力挂起只是一项政治活动,是在权力清单制度推行过程中伴生的政治附属品,其行为依据来自党和国家的政策,而非法律、法规,更遑论宪法依据。因此,现实中的行政权力挂起会表现出过度奉迎政治需要的官僚倾向,也因而具有随意性和短期性。作为一项政治活动,行政权力挂起并不会从真正意义上产生组织法上的法律效果,被挂起的行政权力的合法性并不因此而受到影响,行政权力有没有挂起,并不会改变行政权力的基本属性。因此,实践中,职权法定原则依然应当是行政机关需要恪守的基本准则,“对政治问题的考虑和关照,切不可超越合法有效的法律规范”。^⑧

2. 行政权力挂起的法律效力是相对的。从功能主义立场来看,藉由行政自制控权逻辑而催生的权力挂起活动,虽然仍然能够借助政治通道而产生实质上的法律效力,但这种效力仍然是相对的。实践中,这种相对含义表现在两个方面:(1)在行政相对人一端,权力挂起活动只能单向性地对行政机关自己产生作用,权力挂起的适用对象主要是行政主体,而非相对人。对相对人而言,权力挂起的法律效力只能被理解为一种政治干预,而不是行政组织法上的实际执行力。因此,权力挂起并不可能成为一项“违法性阻却事由”,行政机关更加不能因为权力已被挂起,就可以“依清单行政”,而不是“依法行政”,否则就有可能符合行政不作为的构成要件,成立违法行为,相关工作人员甚至于会沾染“玩忽职守罪”。^⑨而且,被挂起的行政权力仍然应该在各地行政权力网上公开透明运行平台上加以公示,行政相对人可以直接从中查到相应的权力事项,并可以根据相关信息请求行政机关提供公共服务;(2)在行政主体一端,权力挂起活动对行政主体的

⑥ 有关行政自制的相关讨论,See also Robert A. Kagan, *Inside Administrative Law*, 84 Colum. L. Rev., 816-832 (1984)。

⑦ 参见前引⑥。

⑧ 陈卫东:《司法机关依法独立行使职权研究》,载《中国法学》2014年第2期。

⑨ 类似案例,请参见长乐市财政局原局长王凯峰因“执行上级文件”被判处“玩忽职守罪”案。参见刘松山:《“红头文件”冲突法律的责任归属——兼评福州王凯峰案》,载《法学》2002年第3期。

控权效果,也只是相对的,或者说是非常有限的,因为它只是建立在“道德义务”的基底之上的。和其他行政自制行为类似,“其可能仅仅具有指导作用,原则上并无法律约束力,行政机关也可以随时改变其内容”。^⑦并且,更为严肃地说,权力挂起行为并不能直接决定行政机关所执掌的权能,实际上,行政权力的行使最终依赖于法律规范,而非权力是否已被挂起。

(二) 行政权力挂起的合法化设计

将行政权力挂起定位为行政自制行为,虽然能够澄清其与职权法定原则、以及行政不作为之间的关系。但这只是一种解释路径,实践中的权力挂起活动,根本不可能严格遵循“行政自制”的控权逻辑而在法律效力上保持歉抑性,尤其是在我国“政治决定法律”的现实环境之中,^⑧这种反差可能会更加明显。因此,行政权力挂起活动虽然在组织法上不是名正言顺的,但却有可能从实质上起到组织法的效果,打乱现有权力编排,破坏职权法定原则。^⑨因此,“好的最大敌人是最好”,^⑩我们必须要在制度定位以外做更为彻底的合法化设计。概括来说,这可以从如下两个方面展开:

1. 从政治行为向法律行为转变。如果仅仅依靠政治力量的推进,行政权力挂起就只能在“行政自制”的范围之内做权力梳理工作,不可能十分正当地在组织法上发声。而且,其仅仅只能依靠行政机关的自觉,我们不能诘难所有行政主体都对此予以接受。因而,这种依靠道德义务的制度布置,实际上是没有任何保障的,是马克思·韦伯眼中所鄙夷的“一种对后果不负责任的做法”。^⑪因此,行政权力挂起必须从“政治行为”向“法律行为”转变,只有通过这种身份上的过渡,权力挂起才能从法教义学上获得行政组织法的认可,才能十分正当地对行政权力予以处分。

实践中,其可以借由如下三方面实现这一转变:其一,在行为依据上,行政权力挂起活动的发动,必须来自于法律法规的规定,而非党的政策或政府文件,必须改变现阶段以政策推行制度的做法。而且,需要注意,“对政府权力的限制必须着眼于制度建设……要使改革真正取得成效,使权力清单的建构达到预期目的,必须将改革措施制度化、法律化”。从根本上来说,这也是行政组织法上职权法定原则的应有之义;^⑫其二,在决定权限上,应当尽可能地由现在的政府主导型向立法机关主导型转变,将是否需要挂起的决定权限交由地方人大及其常委会,这一方面更加契合职权法定原则的要求,同时

^⑦ See William Funk, *A Primer on Nonlegislative Rules*, *Administrative Law Review*, 2001, 53, p. 1322.

^⑧ 陈金钊:《实质法治思维路径的风险及其矫正》,载《清华法学》2012年第4期。

^⑨ 譬如,《常州市“三合一”网络平台行政权力数据库维护管理办法》(常政办发[2010]119号)第25条规定:“本办法所称行政权力流程挂起,是指进入市‘三合一’网络平台运行的行政权力,因法律法规对行政权力流程的特别规定或因国家政策调整等特殊情形的发生,需增加部分环节的中止功能,对该行政权力办理时限暂停计算的一种行政权力流程运行处理措施”。

^⑩ [德]黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆2009年版,第226页。

^⑪ “遵照纯粹的信念伦理去追求一种终极的善,这个目标很可能会因此受到伤害失信于好几代人,因为这是一种对后果不负责任的做法”。[德]马克思·韦伯:《学术与政治》,冯克利译,生活·读书·新知三联书店1998年版,第115页。

^⑫ 王克稳:《行政审批(许可)权力清单构建中的法律问题》,载《中国法学》2017年第1期。

另一方面也能够从整体上提高权力挂起行为的民主正当性。当然,如果现实中确实存有困难,我们也可以在实质化的职权法定原则的理解上,^⑦将由“行政法规”、“规章”等行政立法行为设定的行政权力,交由其设定机关自行加以裁决。实践中,可参见前述《黑龙江省人民政府关于推行政府权力清单制度的指导意见》的如下规定:“有法定依据,但不符合全面深化改革要求和我省实际,没有管理对象,多年不发生管理行为,一时又难以通过修改相关法律法规规章调整或取消的行政权力,经该行政权力设定机关同意后可以暂时停止实施。需要恢复实施的,须经设定机关同意后方可行使”。^⑧其三,在参照标准上,一项行政权力是否真的需要被挂起,理应以法律、法规以及规章的相关规定为准则,而不是行政机关根据自己的政治意愿和价值选择自行裁决。而且,需要加以区分的是,我们至少需要结合我国《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政强制法》中有关行政处罚、行政许可、行政强制设定权的相关规定,对与它们相冲突的行政权力,直接予以清理或取消,而不是将其挂起或者冻结。

2. 从封闭行为向开放行为转变。现阶段,权力挂起往往是被囊括在权力清单中一并制作的,主要是由行政机关根据工作习惯自行决定,整个过程较为专断,“各部门基本上采用的都是‘闭门制作’的方式,制作过程不公开,公众无参与”,^⑨“对外公开的只是讨论的成品,而并非讨论的过程”。^⑩很明显,这与“政事裁决于大多数人的意志”的基本规则有悖,^⑪不利于公民对此予以监督。因此,权力挂起工作还需要从先前的封闭行为向开放行为转变,在挂起过程中引入公众参与机制,搭建不同利益交流、协商、妥协的平台,“让公民做更为直接的言辞陈述和利益表达”,^⑫从而在这一过程之中实现“政策和决定的合法化”。^⑬

从功能上来说,公众参与对权力挂起的功效表现在两个方面:其一,可以提高权力挂起行为的民主正当性,减缓其对职权法定原则的冲击和破坏。实践中,部分行政权力是由立法机关设定的,^⑭按照上述设计,对于这一部分行政权力是否需要被挂起,由于是交由立法机关裁决的,因而是具有完全的正当性的,这无可厚非。但问题在于,仍然有

⑦ 所谓实质化的职权法定原则,是一种对职权法定原则的扩大化理解,主张职权法定原则中的“法”,并不单单包括“法律”,还应当包括“行政法规”、“地方性法规”、以及“规章”。需要注意的是,实际上,这种立场与我国现行行政法律体系是吻合的。一方面,在实体法上,我国《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政强制法》都承认规章具有授权资格;同时另一方面,在程序法上,我国《行政诉讼法》也在2015年修订时,将规章加入了授权依据的行列。

⑧ 《黑龙江省人民政府关于推行政府权力清单制度的指导意见》,黑政发〔2015〕9号,2015年3月7日公布。

⑨ 前引⑤,杨登峰文。

⑩ [英]威廉·韦德:《行政法》,徐炳等译,中国大百科全书出版社年版,第558页。

⑪ [古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1965年版,第312页。

⑫ 熊樟林:《裁量基准制定中的公众参与——一种比较法上的反思与检讨》,载《法制与社会发展》2013年第3期。

⑬ 王锡锌:《行政正当性需求的回归——中国新行政法概念的提出、逻辑与制度框架》,载《清华法学》2009年第2期。

⑭ 譬如,《行政处罚法》第9条:“法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚,只能由法律设定”;《行政强制法》第13条:“行政强制执行由法律设定。法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请人民法院强制执行”。

大多数的行政权力来自于行政立法的授权,^⑤行政机关自己就可以决定是否需要被挂起。很显然,这与严格意义上的职权法定原则有悖,与传统的一元民主制亦不相容,“是一个不得予以容忍的祸害”。^⑥倘若它要在一国宪政体制的“正当性链条”中获得接纳,就必须对此加以必要的补充。在20世纪的公法学理论中,用以解决这一问题的最好方法,就是高度效仿立法程序的“公众参与”;其二,有利于集思广益,弥补行政机关在信息获取上的短板,保证行政权力挂起工作的科学性和全面性。而且,更为重要的是,公众参与可以保证各种受影响的利益主体了解行政机关在权力挂起过程中的利益衡量,消解公众疑虑,增加可接受性。^⑦很显然,对于权力挂起中可能出现的“行政不作为”问题而言,这无疑是一个较好的预防策略,因为在公众参与程序之后,老百姓对被挂起的行政权力有可能是知情的。

实践中,需要特别注意的是:其一,公众参与最为简单的方式就是信息公开,其往往被称为“纯粹性公布”,^⑧是行政权力挂起的行为底线。根据信息公开的要求,权力挂起的依据、标准、以及结果都应该公布于众,让公众知晓,这在《政府信息公开条例》上也可以找到依据。^⑨而且,被挂起的行政权力,虽然不能进入权力清单之列,但同样是合法的权力,仍然需要对外公开,列入各级人民政府的权力库中。^⑩实践中,我们要坚决禁止诸如“不在行政权力网上公开透明运行系统进行网上运行”之类的做法,^⑪严格区分权力挂起的政治效果和法律效果;其二,同样需要区分的是,允许公众参与,并不等同于说直接让公民决定究竟哪些行政权力应当被挂起而不用。“政策制定是一场很难玩的游戏,因为任何人都可以玩,而且也确实在玩,但是规则只有几条”。^⑫作为行政自制行为的权力挂起行为,决定了其在本质上就是一种自我向善的道德行为,不能奢望行政机关将自己所享有的处分权,交由一个惟“经验主义”为核心理念的公众参与机制。我们只能说,需要通过公众参与平台让老百姓参与到决策过程之中从而充分地进行利益表达。行政权力最终是否需要被挂起,实际上仍然需要由设定机关自己定夺,因为这更多地是一项受制于技术、信息、成本、政治等要素的理性选择问题;其三,公众参与范围并不限于是否需要权力予以挂起问题上,还可以被延伸至是否需要被解挂之中。实践中,一旦出现公众质疑被挂起的行政权力的法律效力时,行政机关应当给予充分的尊重,并迅速予

⑤ 譬如,《行政处罚法》第13条:“尚未制定法律、法规的,前款规定的人民政府制定的规章对违反行政管理秩序的行为,可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚”。

⑥ 许宗力:《法与国家权力》,台湾月旦出版社1993年版,第182页。

⑦ 参见前引⑬,喻少如文。

⑧ 参见张文贞:《行政命令订定程序的改革》,台湾大学法律研究所1995年硕士论文,第154页。

⑨ 譬如,《政府信息公开条例》第9条:“行政机关应当主动公开反映本机关机构设置、职能、办事程序等情况”。

⑩ 譬如,参见南京市鼓楼区《行政权力事项挂起与保留的相关说明》:“行政权力事项挂起后,在市级前台(南京市政务大厅)依旧可以看到,在市级后台(市监察监控系统)呈挂起状态现实”。

⑪ 譬如江苏省新闻出版广电局(版权局)《行政权力挂起操作办法》第5条:“经批准挂起的行政权力,不在局行政权力网上公开透明运行系统进行网上运行”。

⑫ [美]盖伊·皮得斯:《美国的公共政策——承诺与执行》,顾丽梅、姚建华译,复旦大学出版社2008年版,第75页。

以解挂。在这一点上,与挂起的决策权分配不同,解挂的决策权可以向行政相对人倾斜,这一方面是为了降低由于权力挂起而引起行政不作为问题的概率,同时也是为了平衡决策权在挂起与解挂中的均衡分配问题。

结 语

诚如埃利希所言:“现在以及任何别的时候,法律发展的重心既不在于立法,也不在于法律科学和司法判决,而在社会本身”。^⑧“挂起”或“冻结”,这两个在传统行政组织法上几乎毫无意义的词汇,竟然通过地方政府实践进入到行政法视野之中,并完成了自己的制度性布置,这不得不说是行政组织法上的一个奇迹。同时,这也从侧面敲打我们注意,在我国,行政组织法的发展是如此滞后,以致于现阶段需要党和政府的政治力量介入,才能催生诸如行政权力挂起之类的新型权力编排方式。

如上所述,行政权力挂起是伴随时下正在推行的权力清单制度而催生的,它不但在行为依据、决定权限等等方面存在着太多的不确定性,而且在传统行政法体系检测下也暗含巨大的制度风险。但是,这并不能扼杀这一全新制度的组织法价值,相反,我们既可以运用行政自制理论对其进行解释,而且也可以超越理论层面,对其进行全方位的合法性设计,从而促使其从政治行为向法律行为转变,从封闭行为向开放行为转变。

Abstract: During the development and reformation of China's administrative organization law, local governments have created a brand-new system. The new variant of local organization law, known as "administrative power suspension", has no clue in the existing administrative law theory system. From the perspective of local legislation practice, power list campaign has brought out power suspension, the new arrangement of administrative power attached to the power list system. However, power suspension is not to create or eliminate administrative power, but to freeze it according to certain procedures. The frozen power will be suspended for long or unfrozen at any time. Legally, the suspended administrative power may be confronted with problems, such as "whether it has legality", and "whether it constitutes the cause of illegality deterrence". Although these problems could be explained on the basis of administrative self-restraint theory, power suspension, as a political activity, is still in the need of institutionalization from normative perspective and clearness in legal validity. Power suspension is supposed to transform from a political act to a legal act, from a closed act to an open act.

(责任编辑:吴 蕾)

⑧ [奥]埃利希:《法社会学原理》,舒国滢译,中国大百科全书出版社2009年版,第1页。